



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: + 1/310/13, 1/213/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

לפני כב' המפקחת יעל ענתבי-שרון

התובעים

(הנתבעים שכנגד)

1. יגאל בר
2. יזהר עירוני
3. עמוס כץ
4. כץ את כץ נכסים בע"מ
5. דורון ראכלין
6. איריס בר אלפסי
7. רפאל בר

ע"י ב"כ עו"ד דן ישעיהו ושי הנג

- נגד -

הנתבעים

(הנתבעים 2-3 התובעים שכנגד)

1. קספר שמואל דוד
2. אורי בן חמו
3. אמיר פרבר

- נגד -

הנתבע שכנגד 8

1. נתן עירוני

פסק דין

תביעה ותביעה שכנגד שעניינן בטענות להשתלטות ובנייה על רכוש משותף.

הערה מקדימה

תביעה זו נדונה, בחלקה, בפני כבוד המפקח הבכיר (כתוארו דאז) ש. הייזלר. כבוד המפקח הייזלר פרש מתפקידו לאחר שמיעת חלק ממסכת הראיות. מכוח סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, הועבר תיק זה לטיפול לשם השלמת שמיעת הראיות והמשך הטיפול בתיק.

תקנה 177 בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, שעניינה "רציפות הדיון", קובעת כי אם נמנע משופט לסיים את הדיון, רשאי שופט אחר לנהוג בעדויות כאילו הוא עצמו שמע אותן, ורשאי הוא להמשיך מן השלב שבו הפסיק קודמו (ראו: ע"א 534/69 אהרן שושני נ' יפה אלזם, פ"ד כד (1) 145 (1970), בעמ' 147; ע"א 79/72 האפוטרופוס לנכסי נפקדים נ' פולק, פ"ד כז (1) 768 (1973), בעמ' 773; ע"א 387/74 יוסף אברהם נ' בתי מרגוע ומלונות "היוזם" בע"מ, פ"ד כט (1) 353 (1974), בעמ' 356; ע"א 577/94 אורות ייצוג אמנים והפקות ואח' נ' גלי עטרי, פ"ד נא (5) 241 (1997) בעמ' 249).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: + 1/310/13, 1/213/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

משלא מצאתי צורך בשמיעת העדויות אשר נשמעו לפני כב' המפקח הייזלר שנית לפניי, בהסכמת התובעים (ראה דברי ב"כ התובעים, פרוטוקול הדיון מיום 1.3.16, עמ' 1 שורה 40) ובהיעדר התנגדות מצד הנתבעים, המשכתי בשמיעת הראיות בשלב בו הפסיק קודמי.

לפיכך, פסק דין זה יינתן מבלי שהעדויות שנשמעו בפני כבוד המפקח הייזלר תשמענה פעם נוספת.

א. העובדות הצריכות לעניין

1. הליך זה עוסק בבית המשותף הידוע כגוש (ש) 30038 חלקה 2, והממוקם ברחוב המלך גורג' 52 בירושלים (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף רשום בפנקס הבתים המשותפים ככזה והוא מונה 16 חלקות משנה. לבית המשותף תקנון מוסכם.
2. התובעים והנתבעים שכנגד הם בעלי הזכויות בחלק מדירות הבית המשותף:
3. התובע 1 (להלן: "**יגאל בר**") הוא בעליה של תת חלקה 1 במשותף עם התובע 7. בר הוא גם הבעלים של תת חלקה 7 ושל תת חלקה 16.
4. התובע 2 (להלן: "**יזהר עירוני**") , הוא הבעלים של תת חלקה 2, בחלקים שווים עם הנתבע שכנגד 8 (להלן: "**נתן עירוני**"). יזהר עירוני היה בעבר גם בעליה של תת חלקה 5 (אשר כיום בבעלות יאול מרדכי ורבקה, שאינם צד להליך).
5. התובע 3 (להלן: "**כץ**"), הוא הבעלים של תת חלקה 14.
6. התובעת 4, כץ את כץ נכסים בע"מ (להלן: "**כץ נכסים**") , היא בעליה של תתי חלקות 11 ו-13.
7. התובע 5 (להלן: "**ראכלין**") היה בעת הגשת התביעה בעליה של תת חלקה 10. כיום בעליה של תת חלקה 10 היא ברנבאום אלישבע שאינה צד להליך זה.
8. התובעת 6 (להלן: "**איריס בר**") היא בעליה של תת חלקה 12.
9. התובע 7 (להלן: "**רפאל בר**"), הוא כאמור הבעלים המשותף של תת חלקה 1, והוא גם בעליה של תת חלקה 6 בשלמות.
10. הנתבע 1 (להלן: "**קספר**") הוא מי שהיה בזמן הגשת התביעה בעליה של תת חלקה 15 (להלן: "**דירה 15**") נכון להיום רשום כבעלי דירה 15 גיונס ריצ'רד, שאיננו צד להליך זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: + 1/310/13, 1/213/2013

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

11. הנתבעים 2 (להלן: "בן חמו") ו-3 (להלן: "פרבר") הם החוכרים לדורות, בחלקים שווים, של המחסן המסומן בתשריט בספרה 15, והמהווה למעשה חלק מדירה 15 (להלן: "המחסן"). תקופת החכירה היא למשך 999 שנים, החל מיום 23.10.11 ועד 30.9.3010, עם אופציה ל-999 שנים נוספות.
12. המחסן ממוקם בחצר העורפית של הבית המשותף ושטחו, לפי הרשום בטבלת השטחים המהווה חלק מתשריט הבית המשותף, 11 מ"ר (יצוין כי במהלך ניהול ההליכים, ביום 15.12.15, נרשמה העברת שכירות מפרבר לבן חמו, כך שכעת בן חמו הוא החוכר לדירות הבלעדי של המחסן). יודגש כי לפי צו רישום הבית המשותף ותשריט הבית המשותף המחסן מהווה חלק בלתי נפרד מדירה 15 ואינו בגדר הצמדה או יחידה נפרדת ועצמאית.
13. התובעים והנתבעים שכנגד (להלן ולשם הנוחות יכוננו "הנתבעים"), הגישו תביעה זו (תיק 213/13) כנגד הנתבעים, שעניינה במחסן. התובעים מבקשים לחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, להשיב את שטח המחסן לגודלו בהתאם לתקנון ותשריט הבית המשותף, כולל ביטול הגבהתו וצמצום שטחו, להשיב את המצב לקדמותו ובכלל זה לסלק את הריצוף רחב ההיקף מסביב למחסן, להשיב את שטח הבניה בגינה, תיחומה באבנים ונטיעת מחוברים למצב שהיה ערב הפלישה, ולהפסיק את השימוש הבלעדי בשטח הרכוש המשותף. כמו כן מבוקש ליתן צו הקובע כי אין לנתבעים היתר לעשות שימוש חורג במחסן והשימוש היחיד המותר בו הוא כמחסן ולא למגורים.
14. הנתבעים 2-3, הם גם התובעים שכנגד (להלן ולמען הנוחות יכוננו "הנתבעים") הגישו מצדם כתב תביעה שכנגד במסגרתו טענו כנגד שימוש ברכוש משותף ובניה ושינוי ייעוד שנעשו בדירות התובעים והנתבעים שכנגד (להלן: "התובעים"). בהתאם, ביקשו להורות על מתן צווים שונים (על כך יפורט בהמשך).
15. ברקע הדברים לא למותר להזכיר כי בנוגע לעבודות הבניה במחסן נפתח הליך בהתאם לסעיף 212 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 – הריסה ללא הרשעה (להלן: "חוק התכנון והבניה") בבית המשפט לעניינים מקומיים (תיק מספר 2927/12). במהלך דיון שהתקיים בהליך זה הגיעו עיריית ירושלים ובן חמו להסכמה לפיה יינתן צו הריסה כך שגג המחסן יונמך בחצי מטר ויוחזר למצבו המקורי וייבנה מעליו גג רעפים. משני פתחי המחסן הוסכם כי יש להסיר את הבלוקים באופן שישארו פתחים לא חסומים ותותקן דלת לכל פתח. ביני לביני הוארך תוקפו של צו ההריסה וזאת בכדי לאפשר לנתבע 2 קבלת היתר בניה כדין. לאחרונה, הוארך תוקפו של צו ההריסה עד ליום 1.5.17 (ראה נספח א' לסיכומי הנתבעים 2 ו-3).
16. בתיק זה הוגשו תצהירי עדות ראשית והתקיימו מספר דיוני הוכחות. ביום 12.4.16 ערכתי ביקור במקום בנוכחות באי כוח הצדדים ומקצת התובעים (ובהיעדר הנתבע 1).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: + 1/310/13, 1/213/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

ב. עיקרי טענות התובעים

17. בכתב התביעה נטען כי בשנת 2011, או בסמוך לכך, ביצעו הנתבעים בנייה שלא כדין במחסן ובסביבתו ובכך פלשו לרכוש המשותף ותפסו בו חזקה בלעדית. בתוך כך נטען כי הנתבעים הציבו מיטלטלין ומחוברים ברכוש המשותף בסמוך למחסן זה.

18. לטענת התובעים, הנתבעים הגביהו את תקרת המחסן, הרחיבו באופן אופקי את הקירות, הגדילו את שטח הרצפה של המחסן לשטח ברוטו של כ-20 מ"ר, וזאת תוך פלישה לרכוש המשותף, פריצת חלונות, שינוי מקום הדלתות, הנחת דשא סינתטי, ביצוע ריצוף היקפי רחב היקף וכיוצא בזה. ללא קבלת הסכמת שאר בעלי הדירות לכך כדין.

19. בסיכומיהם טענו התובעים כי אף אם המחסן הורחב אופקית שלא על ידי הנתבעים או מי מטעמם, עדיין יש לקבוע כי מן הבחינה המשפטית הם בעלי הזכויות במחסן שהורחב, שלא כדין, וככאלו חלה עליהם האחריות לדבר. נטען, כי היות והנתבעים היו מודעים בעת רכישת זכויותיהם במחסן לכך שהוא הורחב מעבר לשטחו הרשום, הרי שהם מושתקים ומנועים מלטעון, בחוסר תום לב, להיעדר אחריותם להרחבה זו.

20. עוד טוענים התובעים כי במחסן מבוצע שימוש חורג והוא עבר "הסבה" לדירת מגורים המושכרת לצדדים שלישיים. לצורך הסבה זו בוצעו משיכות של כבלי חשמל מעל הרכוש המשותף, לרבות מעל שביל הגישה לחצר העורפית (בין הבית המשותף למחסן), באופן הפוגע בחזות הבניין ובצורה העלולה לסכן את דיירי הבית המשותף.

21. התובעים מדגישים בטיעוניהם כי יש לקבל את התביעה גם כנגד הנתבע 1, וזאת בהיותו בעל המחסן הרשום בעת הרלוונטית לכתב התביעה. לטענת התובעים, מעבר לרישומם כבעלים בלבד, הרי שהראיות שהוצגו בהליך מעידות כי קספר ידע אודות הרחבת המחסן שלא כדין והחכיר אותו לנתבעים 2-3 בדיעה שנעשו בו חריגות בנייה שלא כדין, ומכאן שיש לתן את הצווים המבוקשים גם כנגדו.

22. התובעים מכחישים מכל וכל כי קספר העניק לנתבעים 2-3 זכויות בנייה במחסן, וטוענים כי לפי התוכניות החלות כלל לא ניתן לאפשר תוספת בנייה למחסן המצוי מחוץ לקווי בניין, וממילא לא ניתן להעביר בנסיבות אלו זכויות בנייה למחסן. מעבר לכך נטען כי גם אם העברה שכזו הייתה אפשרית, יש בה כדי לפגוע מהותית בזכויות הבנייה השייכות לתובע 1 על מחצית הגג, ועל כן אין כל תוקף להסכמת קספר ללא הסכמת התובע 1.

ג. עיקרי טענות הנתבעים

23. הנתבע 1 טוען כי יש לדחות את התביעה כנגדו בהיעדר כל עילת תביעה. לטענת קספר, הוא היה בעליה של הדירה, בנאמנות, לתקופה קצרה. בתוך כך החכיר לתקופה של 999 שנים את המחסן לנתבעים, עם אופציה ל-999 שנים נוספות. בנסיבות אלו, נטען, אין לו למעשה כל זיקה או קשר למחסן. בתוך כך נטען כי כל בניה או שימוש שנעשו במחסן נעשו כך שלא בידיעתו או בהסכמתו ואין לקשור אותו לנושא זה כלל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: + 1/310/13, 1/213/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

24. קספר טוען כי אף הוכח במסגרת שמיעת הראיות בתיק כי הוא לא ידע על הבנייה במחסן וברכוש המשותף, ולא היה שותף לה בכל דרך שהיא. לטענת קספר, התביעה הוגשה ממניעים זרים לאחר שהמשא ומתן למכירתה של דירה 15 ובכלל זה המחסן לכך נכשלה. עוד טען קספר כי אין לו כל שליטה וחזקה במחסן, וממילא אין בידיו אפשרות מעשית לבצע את הצווים המבוקשים, ככל שיינתנו.
25. הנתבעים 2-3 טוענים בכתבי הגנתם כי רכשו את המחסן בשטחו כפי שהוא היום. לטענתם, העובדה כי בתשריט הבית המשותף מסומן המחסן בשטח אחר (11 ס"מ) אין בה ולא כלום. לטענתם, לא הרחיבו ולא הגדילו את שטחו הקיים של המחסן.
26. לטענת הנתבעים 2-3, החלטת בית משפט השלום (כב' השופטת תמר נמרודי) בתיק 2927/12, מהווה מעשה בית דין או פלוגתא פסוקה, ואף מהווה השתק שיפוטי. לטענת הנתבעים בהחלטה זו נקבע כי לא בוצעו עבודות הריסה או בנייה של קירות וממילא כי לא הוגדל שטחו של המחסן. נטען כי ניתן צו הריסה באופן שנקבע כי יונמך גג המחסן בחצי מטר ויוחזר למצבו המקורי ויבנה מעליו גג רעפים. כמו כן נקבע כי יש לפתוח שני פתחים שנאטמו, ולהתקין דלת בכל אחד מהם. ביצוע הצו נדחה על מנת שיהיה בידי הנתבעים להשיג היתר בניה. בכתב ההגנה ואף בסיכומיהם נטען כי הנתבעים 2-3 עמלים על השגת היתר בניה כאמור.
27. הנתבעים 2-3 טוענים עוד כי לא פלשו לשטחי הרכוש המשותף וכי העבודות שביצעו נעשו בתחום המחסן. לטענת נתבעים אלה, הם היטיבו עם התובעים והבית המשותף, ובין היתר שיפרו וטפחו חצר מוזנחת.
28. הנתבעים 2-3 אף מדגישים כי המחסן לא הורחב על חשבון הרכוש המשותף, ומכל מקום כי גם אם בוצעו עבודות הרחבה, אלו בוצעו בעבר הרחוק בהסכמת בעלי הדירות שהיו באותה עת וללא כל התנגדות מצדם. בנסיבות אלו נטען כי התביעה התיישנה או הושהתה זמן רב יתר על המידה.
29. הנתבעים מוסיפים וטוענים כי על פי התקנון המוסכם, זכויות הבנייה בבית המשותף שייכות בחלקן לבעל דירה 15, וזה הסכים מראש (כמפורט בשטר החכירה), שהנתבעים יעשו שימוש באחוזי הבנייה השייכים לדירה 15, ככל שיהיה צורך, לביצוע כל בנייה ביחידה שיחפצו בה. בנסיבות אלו נטען כי די בהסכמת בעל יחידה 15 ולתובעים אין כל פתחון פה בעניין.
30. לחלופין ובהשלמה נטען בכתב הגנתם כי נוכח בניה שהוסיפו הנתבעים לדירותיהם על חשבון הרכוש המשותף יש לראות בהם, מכוח העובדה שהרחיבו את דירותיהם, כמי שנתנו הסכמה לכל בנייה שביצעו הנתבעים. לטענת הנתבעים, מרבית בעלי הדירות (למעלה מ-3/4), הרחיבו את יחידותיהם ולפיכך אין הנתבעים מנועים מלבצע כל עבודה במחסן. בנסיבות אלו נטען גם כי היות ויש לראות ב-3/4 מבעלי הדירות כמי שנתנו הסכמתם הקונסטרוקטיבית, נוכח הרחבות דירותיהם שלהם, אין הנתבעים זקוקים כלל להסכמות התובעים. בסיכומיהם, זנחו הנתבעים 2-3 טענה זו, אולם טענו כי נוכח העובדה שגם בדירות התובעים בוצע



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: + 1/310/13, 1/213/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

שימוש חורג מזה הקבוע תקנון המוסכם, יש ללמוד כי זה היה דפוס ההתנהלות הקבוע בבית המשותף, ויש לראות בכך הסכמה מכללא גם לשינוי יעוד המחסן למגורים.

31. באשר לכבלי החשמל טוענים הנתבעים כי אלו קיימים מימים ימימה, והם נמשכו מתת חלקה 15. נטען כי הנתבעים הם דווקא אלו שהצניעו כבלים אלו והצליחו לשלבם בתשתית הקיימת.

ד. דיון והכרעה

32. בעל דירה זכאי לעשות ברכוש המשותף שימוש סביר וזאת ללא צורך בהסכמת בעלי הדירות. הפסיקה פירשה "שימוש סביר" כשימוש לפי תנאי המקום והזמן, התואם את ייעודו של הרכוש המשותף ואינו מונע שימוש דומה מאחרים (ראה ע"א 549/73 וינטרס ואח' נ' זמורה ואח', פ"ד כח 645(1), ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג ואח', פ"ד כח' (2) 817, המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 14-18 י-ם, פ"ד לה 277).

33. עת מדובר בביצוע עבודות בניה כאלו או אחרות ברכוש המשותף, או בשינוי פני הרכוש המשותף, הרי שככלל אין מדובר ב"שימוש סביר" ולפיכך יש צורך לקבל את הסכמת בעלי הדירות כדין.

34. באשר לרף הסכמת בעלי הדירות הנדרש, הרי שהכלל הוא כי כאשר מדובר בביצוע עבודות כלשהן הפוגעות ברכוש המשותף, ושאינן בהן משום הצמדה של חלק מהרכוש המשותף לדירה פלונית, או זכות שימוש ייחודית בו, די בהסכמת רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית. סעיף 22 לתקנון המצוי קובע כך:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לעניין זה: "פגיעה ברכוש משותף" - לרבות פגיעה בחזונו החיצוני התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבנייה".

35. שונים הם פני הדברים עת מדובר בתוספת בנייה ברכוש המשותף לשם שימוש הייחודי של בעל דירה זה או אחר. במקרה מסוג זה, הרי שככלל נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות. סעיף 62 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") קובע כי את הוראות התקנון ניתן ככלל, לשנות ברוב של בעלי הדירות ששני שליש מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, אולם מוסיף וקובע כי "אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות".

36. הנה כי כן, על פי הוראות החוק, רק בהסכמת כל בעלי הדירות, ניתן להצמיד חלק מהרכוש המשותף לדירה פלונית, ולמעשה ליתן זכות קניינית ברכוש המשותף. הוא הדין גם לגבי עשיית שימוש ייחודי ברכוש משותף, אף אם אותו חלק לא הוצמד לדירה מסוימת במרשם המקרקעין (ראה: 2525/92, גבי וקרני ואוכרברג נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז' (5) 850, רע"א 698/85, בן צור ואח' נ' נעים ששון ואח', תק-על 87 (2) 732, י. וייסמן, דיני קניין בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), עמ' 455-454).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: + 1/310/13, 1/213/2013

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

37. חריג לכלל זה הוסף במסגרת תיקון 18 לחוק, משנת 1995. בחלק מתיקון זה הוסף סעיף 71 לחוק, בו נקבע כי בתנאים מסוימים זכאי בעל דירה לבנות על הרכוש המשותף לצורך ביצוע הרחבה לדירתו, אף בהיעדר הסכמת כל בעלי הדירות, ודי לשם כך ברוב מיוחד של בעלי הדירות, הוא רוב של 3/4 מבעלי הדירות אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

מן הכלל אל הפרט

38. אפתח בטענות הנוגעות **לכתב התביעה**. כאמור, בכתב התביעה נטען כי הנתבעים הרחיבו את המחסן באופן בו סיפחו אליו חלקים מהרכוש המשותף, ריצפו את שביל הגישה אליו ואת סביבותיו, השתלטו על חלק מהחצר המשותפת הסמוכה למחסן, העבירו כבלי חשמל מתת חלקה 15 (המצויה בקומה החמישית) אל המחסן וזאת דרך מעבר ברכוש המשותף. כל זאת, כנטען, ללא הסכמת בעלי הדירות כדין. הנתבעים, כאמור, הכחישו את טענות התובעים וטענתם העיקרית היא כי לא ביצעו הרחבה של שטחי המחסן כלל.

39. ראשית, ולשם הבנת התיאורים העובדתיים, יש לציין כי המחסן משמש כיום למגורים ואף הוכשר על ידי הנתבעים 2-3 לשמש כזה. בביקורי במקום ניתן היה להבחין כי המחסן מושכר לצרכי מגורים, וכאמור, כי בפועל נעשה בו שימוש כזה.

40. בתחילת הדברים אבחן- מן הבחינה העובדתית- מהן העבודות אשר בוצעו במחסן וסביבותיו והאם הן עולות כדי השתלטות על רכוש משותף. ככל שאמצא כי אכן כך, יש להמשיך ולבחון מהו רף ההסכמות הנדרש לנתבעים לשם הותרת המחסן, כפי שהוא היום, על תילו. בהמשך, ובהתאם לצורך, אבדוק האם אכן אוחזים הנתבעים בהסכמות הנדרשות לשם כך כדין.

41. אקדים תוצאה להנמקה ואציין כבר עתה כי מצאתי שהנתבעים 2-3 אכן ביצעו עבודות בניה במחסן באופן בו הגביהו את מחסן הגג, וכל זאת על חשבון הרכוש המשותף ומבלי לקבל את הסכמת בעלי הדירות לכך. כמו כן מצאתי כי הסיגו את גבול הרכוש המשותף באופן בו ריצפו שטח הסמוך למחסן ואף עושים שימוש ייחודי בשטח חצר הסמוך למחסן. כך גם מצאתי כי המחסן מחובר בכבלים ובצינורות לתשתיות דירה 15, דבר המהווה פגיעה בחזות החצר המשותפת. עבודות אלו בוצעו כולן, מבלי לקבל את הסכמת בעלי הדירות כדין. לפיכך, הרי שדין התביעה בהקשר זה להתקבל ועל הנתבעים 2-3 להשיב את המצב לקדמותו. ביחס לנתבע 1 מצאתי כי יש מקום לדחות את התביעה נגדו.

42. מנגד, לא הוכח כי הנתבעים ביצעו עבודות בניה במחסן באופן בו הרחיבו את שטחו של המחסן הרחבה אופקית של הקירות, מצדדיו (להבדיל מהרחבת שטחו מעלה, אל עבר הגג, באמצעות הגבהת הגג). כך לא מצאתי כי ביצעו שינוי בפתחי המחסן שלא כדין. לפיכך לא מצאתי ליתן כל סעד בהקשר זה.

43. להלן אפרט את נימוקיי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: + 1/310/13, 1/213/2013

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

הרחבת שטח המחסן מעלה

44. בהקשר זה נראה כי העובדות ברורות ומוסכמות ברובן. במהלך חקירותיהם הנגדיות הודו הנתבעים 2-3 בהרחבת גג המחסן, וזאת ללא קבלת הסכמת בעלי הדירות לכך. בהקשר זה העיד בן חמו כי:

"הגג הוגבה בכ-40-50 ס"מ. הצהרתי על כך" (ראה פרוטוקול הדיון מיום 1.3.16, עמ' 8 שורות 27-28) ובהמשך- "לשאלתך אני מאשר שהגבהנו את הגג" (עמ' 9 שורה 17).

45. במצב דברים זה אני מורה לנתבעים 2-3 להנמיך את גג המחסן ב-50 מטרים, להחזירו למצבו המקורי. יש לעשות כן בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין.

הרחבת המחסן אופקית

46. הנתבעים 2-3 הכחישו כי הרחיבו את שטח המחסן אופקית, וחזרו וטענו כי רכשו את המחסן בשטח של כ-16 ס"מ כפי שהוא עודנו.

47. בחוות דעת המודד אברהם ארנסטר מיום 7.7.13, אשר הוגשה מטעם התובעים (נספח ג' לכתב התביעה), מצוין כי שטחו של המחסן, כפי שנמדד על ידי ארנסטר, עומד על 16.5 מ"ר נטו (ראה בסעיף 2 לחוות הדעת). הנתבעים לא ביקשו לחקור את המומחה על חוות דעתו והסכימו, למעשה, כי זהו שטחו של המחסן, אולם טענו כי כך רכשו אותו.

48. יזהר עירוני העיד כי ראה את הגבהת הגג, אולם אישר בחקירתו הנגדית כי לא היה עד להרחבה אופקית כלשהי של המחסן:

"ש. בעת שהחלו נתבעים 2-3 לבנות לגובה את המחסן, האם ראית שהם בונים/מרחיבים את המחסן?

ת. כשאני הייתי שם פירקו את הגג, היה לכלוך מכל כיוון. הגג הוגבה. לא יכול לומר לך שנשברו קירות או הורחבו קירות בעת שהייתי שם". ובהמשך- "לא יודע מתי הרחיבו, יכול להיות שקנו את זה כך...". כך גם ציין בהמשך חקירתו בהתייחס להרחבה האופקית של המחסן כי: "יכול להיות שזה קרה ב-5 השנים האחרונות" (ראה פרוטוקול הדיון מיום 20.9.15, עמ' 5 שורות 2-3, 16-17, 27-28).

49. לתצהירו של יגאל בר צורפו תמונות רבות (37 במספר) וזאת כדי ללמוד מהם על שלבי ביצוע הבנייה במחסן (ראה נספח ד1-37 לתצהיר יגאל בר). תמונות אלו מלוות את כל תהליך הבנייה וניתן להסיק מהן בנקל על הרחבת הבניה במחסן כלפי מעלה, היינו הגבהת הגג (ראה למשל תמונה ד4, ד7 ו-ד8, ד21, ד23). עם זאת, התמונות אינן מתעדות הרחבה אופקית של המחסן. יגאל בר אף אישר בחקירתו הנגדית כי לא ראה במו עיניו בניה של קיר או קיר מפורק (ראה פרוטוקול מיום 20.9.15, עמ' 8 שורות 20-24), ואף אישר כי אינו יכול לומר



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: + 1/310/13, 1/213/2013

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

בוודאות כי הקיר הצפוני והמערבי נבנו בתקופתו של הנתבע 2 (ראה: פרוטוקול מיום 20.9.15, עמ' 10 שורות 17-19, ראה גם בעמ' 11 שורה 3).

50. עיון מסמכי הבית המשותף אכן מלמד כי שטחו הרשום של המחסן הוא 11 מ"ר, כאשר אין חולק כי שטחו נכון להיום עומד על כ-16.5 מ"ר. דא עקא, כי במסגרת הליך זה לא הוכח כי הנתבעים הם שביצעו את ההרחבה. מנגד, קיימות ראיות המעידות כי שטח המחסן, עוד בטרם מכירתו לנתבעים, היה גדול מזה הרשום במסמכי רישום הבית המשותף ועמד על שטח הזהה לשטחו היום, כ-15-16 מ"ר.

51. כך למשל, עולה מהסכם המכר שנערך בין הנתבע 1 לבעלת תת חלקה 15 דאז, הגב' אסתר (אשכנזי) סבח (נספח א' לתצהיר קספר). בסעיף 1 להסכם זה צוין כי המחסן הוא בשטח "15 מ"ר". היות והסכם זה נחתם עוד בטרם שהנתבעים 2-3 רכשו זכויות כלשהן במחסן, ניתן ללמוד כי שטחו של המחסן, עוד טרם שנכנסו לתמונה, עמד על כ-15 ס"מ. מדובר בשטח זהה או זהה בקירוב לשטחו של המחסן כפי שנמצא על ידי ארנסטר. גם בחוזה החכירה שנחתם בין קספר לבן חמו ופרבר מצוין שטח המחסן "כ-16 מ"ר" (ראה נספח ב' לתצהיר קספר).

52. בנוסף לכך, בטיטוט הסכם מכר למכירת יחידה 15, על הצמדותיה, בין קספר לכך (ראה נספח ג' לתצהיר קספר) צוין כי שטח המחסן הוא "15 מ"ר" (כך ניהל משא ומתן עם קספר לצורך רכישת תת חלקה 15 ובמסגרת זו הוחלפו טיטוט הסכם בין הצדדים. בסופו של יום, כידוע, המשא ומתן לא נשא פרי). על אף שיגאל בר העביר הערות לטיטוט זה, (כעולה מהרישומים על גבי מסמך זה, ראה עדות קספר בפרוטוקול הדיון מיום 1.3.16, עמ' 6 שורה 26), הוא לא העיר דבר בנוגע לשטח המחסן המתואר בו.

53. כך, גם בחוות דעתה של האדריכלית רונית ראובני (להלן: "ראובני"), מטעם התובעים, לא היה די כדי לבסס ראייה בדבר הרחבת המחסן בתקופה בה היו הנתבעים או מי מהם בעלי הזכויות בו. ראובני ביקשה לבסס מסקנה זו על השוואה בין שתי תכניות מדידה שונות (ראה בסעיף 20 לחוות דעתה, מוצג נ/1). דא עקא, כי תכניות מדידה אלו לא נוגעות למחסן אלא לשטח החלקה בשלמותה. גם בחקירתה הנגדית אישרה, למעשה, ראובני כי אין בתכניות המדידה עליהן הסתמכה נתונים באשר לשטח המחסן (ראה פרוטוקול הדיון מיום 29.4.15, עמ' 6 שורות 14-16).

54. ב"חוות דעת מומחה לפענוח תצלומי אוויר" (צורפה לבקשת התובעים מיום 30.11.15), אותה נתן מר ערן וולפסון (להלן: "וולפסון"), אין כדי להעלות או להוריד. בחוות דעתו משווה וולפסון בין שתי תמונות של המחסן- האחת שצולמה ביום 16.5.09, וממנה עלה כי צדו הדרומי של המחסן אשר צולם ביום 16.5.09 הוא כ-3.5 מ"ר, והאחרת, אשר צולמה ביום 7.5.10, שם נראה צידו הדרומי של המחסן בשטח של כ-5 מ"ר. אף שיש לקבל חוות דעת זו כלשונה (שכן הנתבעים נמנעו מלחקור את וולפסון על חוות דעת זו ואף לא עשו שימוש בזכותם להציג חוות דעת נגדית מטעמים), הרי שלא מצאתי כי יש בה כדי ללמד כי אכן המחסן כולו הורחב באופן הנטען, הינו מ-11 מ"ר לכ-20 מ"ר. כל שיכולה ללמד חוות הדעת היא כי קיר מסוים במחסן



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: + 1/310/13, 1/213/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

הוארך מ-3.5 ס"מ ל-5 ס"מ. חוות הדעת לא בוחנת את שטח המחסן כולו, אין בה מידע לגבי קירות אחרים במחסן או לשטחו הכולל ולפיכך לא ניתן להסתמך על האמור בה לשם קביעת ממצא ברור ולפיו המחסן כולו הורחב, בהיקף הנטען או אף בחלקו, דווקא בין 16.5.09 ל-7.5.10. לפיכך, כאמור, לא הוכח כי הנתבעים, מי מהם או מי מטעמם, הרחיבו את המחסן על חשבון הרכוש המשותף. כך גם לא הוכח באיזו תקופה הורחב, ולא הוכח כלל כי היה זה בזמן בו מי מהנתבעים היו בעלי הזכויות במחסן.

55. מסקנתי היא, אם כן, כי לא הוכח כי הנתבעים, או מי מהם, ביצעו הרחבה אופקית של המחסן, בין בעצמם או בין באמצעות מי מטעמם.

56. התובעים טענו בסיכומיהם כי אף אם הנתבעים לא ביצעו בעצמם את עבודות ההרחבה, הרי משעה שהוכח כי המחסן אכן הורחב מעבר לשטחו הרשום, חלה האחריות על הנתבעים, כבעלי הזכויות בו, להשיב את המצב לקדמותו. אמנם, שטחו של המחסן כיום הוא כ-16 ס"מ, היינו הוא אכן הורחב מעבר לשטחו הרשום בתשריט הבית המשותף. עם זאת, מהראיות אשר הוצגו בהליך זה לא ניתן לדעת באיזו תקופה הורחב המחסן, כך לא ניתן לשלול כי הדבר נעשה לפני שנים רבות. משאין די ראיות לקביעת ממצא בהיבט זה, כך גם אין ראיות באשר לשאלת ההסכמה. לא ניתן לשלול כי המחסן הורחב לפני שנים ארוכות, בהסכמת בעלי הדירות דאז, מה גם שככל שאכן כך, ייתכן כי התביעה כולה התיישנה.

57. במצב דברים זה מסקנתי היא כי היות ולא הוכח כי מי מהנתבעים הרחיב את המחסן, ומשלא הוכח באיזה מועד הורחב המחסן, הרי שלא ניתן לקבוע כי ההרחבה בוצעה שלא כדין. **לפיכך, בהיבט זה של הרחבתו האופקית של המחסן - התביעה נדחית.**

סגירת ופתיחת פתחים במחסן

58. בסוגיית סגירת ופתיחת פתחים במחסן הוכח כי אכן נסגרו פתחים קיימים ונפתחו פתחים חדשים במחסן. הסוגיה בה יש לדון בהקשר זה היא האם שינוי הפתחים, כפי שנעשה, מצריך את הסכמת בעלי הדירות, או חלקם, וככל שכן - האם אוזרים הנתבעים בהסכמות הנדרשות כדין.

59. מהראיות שהוצגו בהליך עולה התמונה הבאה: כעולה מתשריט הבית המשותף, במקור היה בנוי המחסן כך-מחסן "בסיסי" בצורת ריבוע המהווה את מרבית שטחו של המחסן, ולו דלת מצדו המזרחי. בצדו הדרום-מערבי של המחסן היה קיר מפריד. הכניסה לצדו הדרום-מערבי של המחסן נעשתה דרך שתי דלתות-דלת אחת הובילה למחסן קטן מלבני, ודלת אחרת הובילה לחדר שירותים.

60. בביקורי במקום ניתן היה לראות כי חל שינוי בפתחים אלו: מהצד הדרום מערבי, במקום שתי דלתות קיימת דלת אחת בלבד (כפי שניתן לראות בתשריט הבית המשותף - מוצג ת/2), אשר בפועל מהווה את דלת הכניסה הראשית למחסן, המשמש כאמור, כיום למגורים (ראה גם תמונות ד/18, ד/19 לתצהיר יגאל בר). מן הצד



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: + 1/310/13, 1/213/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

הצפון- מערבי של המחסן קיימת עדיין דלת במיקום זהה או כמעט זהה (ייתכן הבדל של סנטימטרים בודדים אם בכלל) ממיקומה המקורי של הדלת (ראה גם תמונות ד/3, ד/6).

61. למעשה, השינוי העיקרי, מבחינת הפתחים, הוא פתיחת דלת אחת מן הצד הדרום- מערבי חלף שני פתחים.

62. אמנם, הקירות החיצוניים של המחסן מהווים "רכוש משותף", כעולה מהגדרת המונח "רכוש משותף" בסעיף 52 לחוק. אולם, לא מצאתי כי במקרה הנדון שינוי הפתחים כמתואר לעיל מהווה משום פגיעה ברכוש המשותף, לשם הכשרתה נדרשת הסכמת רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית.

63. למעשה, אין מדובר בפגיעה כלל. כאמור, עודנה קיימת דלת בחזית הצפון מערבית של המחסן. שתי דלתות שהיו בחזית הדרום מערבית נאטמו ותחתם נפרץ פתח חדש על המשמש כדלת. השינוי בפתחים אלו הוא עניין של מה בכך. אין מדובר בדלתות שנפערו מתוך קיר שלא היו בו דלתות בעבר, אין מדובר בדלת שנפרצה חלף חלון, ואף לא בדלתות שנפערו על מנת לאפשר גישה נוחה יותר של באי המחסן לחצר המשותפת. כל שנעשה היה לאחד שתי דלתות לכדי דלת אחת, במיקום סמוך מאוד לדלתות המקוריות. במצב דברים זה מדובר בשימוש סביר ביותר ברכוש המשותף, שאין בו כדי להוביל לפגיעה כלשהי בקירות החיצוניים של המחסן ובחזותו או בחזיתו. **לפיכך, לא מצאתי ליתן כל סעד בהקשר זה.**

השתלטות על החצר המשותפת

64. בכל הנוגע להשתלטות על חלקה של החצר המשותפת, הרי שמצאתי לקבל את טענות התובעים כנגד נתבעים 2-3 במלואן.

65. נראה שהעובדות אינן שנויות במחלוקות, אולם הפירוש שניתן להן על ידי כל אחד מהצדדים הוא אחר לחלוטין.

66. בביקורי במקום נראה בבירור כי החל מהצד הצפון מערבי של המחסן ועד לסיום צדו הדרום מערבי, רוצף שביל גישה במרצפות כחולות – אפורות (להלן: "הריצוף"). הריצוף נעשה על גבי החצר המשותפת, בסמוך מאוד למחסן, ולמעשה נועד להוות שביל גישה למחסן, הכל על מנת לעשות בו שימוש נוח יותר למגורים.

67. בנוסף, מהצד הדרום מערבי של המחסן, ובסמוך לו, יוחד למעשה חלק מהחצר המשותפת לשימוש ייחודי של באי המחסן. מדובר בשטח קרקע המכוסה דשא סינתטי, מונחים עליו ספסלי עץ, ובגבולותיו פרושים בולי עץ על מנת למעשה, לתחום ולהפריד בינו לבין יתר החצר המשותפת (להלן: "חצר המחסן"). מדובר בחצר סמוכה לדלת הכניסה הראשית למחסן. מבט עיניים מלמד באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי חצר המחסן מיועדת לשימוש ייחודי של דרי המחסן ובאי ביתם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: + 1/310/13, 1/213/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

68. אמנם, הן לריצוף והן לחצר המחסן יכולים יתר בעלי הדירות להגיע באין מפריע. אין גידור העוצר זאת מבעדם. אולם, נוכח תחושת אי הנוחות הכרוכה בכך, בבחינת כניסה לשטחו הפרטי של אדם, מובן מאליו כי אלו לא יעשו שימוש באפשרות זו. לפיכך, מדובר באופן מובהק בעשיית שימוש ייחודי ברכוש משותף. בביקורי במקום התרשמתי כך באופן מפורש.

69. מן הבחינה העובדתית, אין חולק כי הריצוף, הדבקת הדשא הסינתטי, הצבת הספסלים, מחסן הפלסטיק, ותיחום השטח בבולי העץ, נעשו בהיעדר הסכמת רוב מבין מבעלי הדירות. בהקשר זה אישר בן חמו בחקירתו כי הם (בן חמו ופרבר) ש"סידרו" את הגינה המשותפת, ביצעו ריצוף היקפי והניחו כר דשא סינתטי (ראה פרוטוקול מיום 10.3.16, עמ' 10 שורות 14-26). כך גם אישר שהדבר בוצע ללא הסכמת בעלי הדירות-

**" ש. לצורך ההסבה של מחסן למגורים, עשיתם תוספת ריצוף, גידור, דשא סינתטי, והכל ללא הסכמת השכנים זה נכון?
ת. כן" (ראה שם, בעמ' 10 שורות 29-31).**

70. במצב דברים זה הרי שמסקנתי היא כי הנתבעים 2-3 ביצעו שימוש ייחודי ברכוש המשותף, וזאת ללא הסכמת בעלי הדירות כדין. לפיכך אני מורה לנתבעים 2-3 להסיר את הריצוף כמתואר לעיל, להסיר מתחומי החצר המשותפת את כר הדשא הסינתטי, הספסלים, ובולי העץ. כמו כן על הנתבעים 2-3 להסיר את מחסן הפלסטיק שהציבו בסמוך לכניסה האחורית למחסן. נאסר על הנתבעים או מי מטעמם לעשות שימוש ייחודי כלשהו בחצר או בחלקו.

כבלי חשמל

71. בביקורי במקום ראיתי כי המחסן מחובר לתשתיות כגון מערכת החשמל באמצעות חיבור לחלקה הנוסף של דירה 15, הממוקמת בקומה החמישית. כבלים אלו עוברים לאורכו של הקיר החיצוני של הבניין ולאחריו, בקו אווירי עד לחיבורם עם המחסן. כבלים אלו פוגעים במראם של הקירות החיצוניים ובעיקר- במראה החצר המשותפת ואף עשויים להוות מפגע פיסי כלפי יתר בעלי הדירות העושים שימוש בחצר המשותפת.

72. לא הוצגו בפני כל ראיות המלמדות כי העברת הכבלים באופן זה, שיש בו משום פגיעה ברכוש המשותף, נעשתה בהיעדר הסכמה של מי מבעלי הדירות.

73. אשר על כן אני מורה לנתבעים 2-3 להסיר את כל הכבלים והצינורות המחוברים את המחסן לתשתיות דירה 15. יש לעשות כן בתוך 30 יום מיום מתן פסק הדין.

התביעה כנגד נתבע 1

74. יש לדחות את התביעה בכל הנוגע לנתבע 1.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: + 1/310/13, 1/213/2013

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

75. בזמנים הרלוונטיים לתביעה קספר היה אמנם בעליה הרשום של יחידה 15, אולם אין חולק כי החכיר את המחסן לידי הנתבעים 2-3 לתקופה של 999 שנים, עם אופציה להארכה ל-999 שנים נוספות.

76. מדובר בדרך אופיינית לעקוף את המגבלה הקבועה בחוק להעברת בעלות על חלק מחלקה (ראה סעיף 13 לחוק הקובע כי: **"עסקה במקרקעין חלה על הקרקע יחד עם כל המנוי בסעיפים 11 ו-12, ואין תוקף לעסקה בחלק מסוים במקרקעין, והכל כשאינו בחוק הוראה אחרת"**, וכן הוראת סעיף 78 לחוק הקובעת כי: **"על אף האמור בסעיף 13 ניתן להשכיר חלק מסוים של המקרקעין"**).

77. בפסיקה נקבע כי לא ניתן להכריע שכל אימת שנכס מוכר לתקופה ארוכה, הופכת מאליה זכות החכירה לזכות בעלות, או קרובה לה, אלא יש לבחון כל מקרה לגופו, ובפרט אל מול התנאים הכלולים בחוזה החכירה. **"השאלה אם חוזה חכירה לדורות כמוהו כהעברת בעלות, נעוצה בסופו של דבר בתוכנו של כל חוזה וחוזה"** (ראה ע"א 355/76, בסו נ' מלאך ואח', פ"ד לא (2) 359). לפיכך נקבע כי את התוצאה יש לבחון בהתאם לגילוי כוונת הצדדים לחוזה.

78. עם זאת נקבע כי **"משאמרנו כי השאלה תוכרע לפי כוונת הצדדים לחוזה החכירה, לא המעטנו מהמשמעות שיש לייחס לכך שחוזה החכירה הוא לתקופה ממושכת, עובדה שהיא ללא ספק נסיבה כבדת משקל בגדר הנסיבות שיש לבחון לצורך הפירוש שיש לתת לכוונת הצדדים שהתקשרו בחוזה מסוג זה. יתרה מזו, ניתן לומר כי כשמדובר בחכירה לדורות לתקופה כה ממושכת, יש יסוד להנחה הפרשנית שבהיעדר ראייה לכוונה אחרת, התכוונו הצדדים להעביר את מירב הזכויות בנכס ככל שהדבר ניתן, ובכך מתקרבת זכות החכירה ככל האפשר לבעלות"** (ראה: רעא 2821/95, שמחה לוסטיג נ' נעמי מייזלס, פ"ד נ (1) 517).

79. בהקשר זה לא למותר לציין את הגדרת המנח **"בעל דירה"** בסעיף 52 לחוק (החל בתוך פרק ו' לחוק העוסק ב"בתים משותפים"): **"בעל דירה - לגבי דירה שהוחכרה לדורות - החוכר לדורות או חוכר המשנה לדורות, לפי העניין, זולת אם נקבע בחוזה החכירה שלעניין פרק זה לא יראו אותם כבעלי דירה"**.

80. הנה כי כן, על מנת לבחון האם במקרה הנדון זכות החכירה שהעברה לבן חמו ופרבר במחסן מתקרבת ככל האפשר לזכות הבעלות, יש לעמוד על תנאי חוזה החכירה בין הצדדים ועל כוונתם המשתמעת בהקשר זה. בתוך כך, יש לבחון האם בחוזה החכירה נקבע במפורש שלצורך הוראות פרק ו' לחוק לא יראו את החוכרים כבעלי דירה. כמו כן, יש להחיל את הכלל לפיו ככל שאין ראייה לכוונה אחרת יש לקבוע כי הצדדים אכן התכוונו להעביר את מירב הזכויות בנכס באופן שזכות החכירה שהועברה זהה כמעט לחלוטין לזכות הבעלות.

81. חוזה החכירה שבין קספר לנתבעים 2 ו-3, ביחס למחסן, מורכב הן מהחוזה עצמו והן מנספח "תנאים מיוחדים" הנלווה לו (נספח ב' לתצהיר קספר). מהוראותיו ניתן לדלות אמירות מהן עולה באופן ברור כי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: + 1/310/13, 1/213/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

כוונת המחכיר היא להעביר לחוכרים את המחסן כמעט ללא סייג. כך למשל עולה מהוראת סעיף 3 לתנאים המיוחדים: **"השוכר רשאי לנהוג במושכר מנהג בעלים מושלם וללא כל הגבלה על זכויותיו, כאילו היה הבעלים של המושכר לכל דבר ועניין"**. כך גם עולה מהוראת סעיף 6 לו המאפשרת לחוכרים לעשות כל עסקה במחסן ללא צורך בהסכמת המחכיר ומבלי שהחוכרים יהיו חייבים בגין כך בתשלום נוסף למחכיר.

82. אם לא די בכך, הרי שמהוראות חוזה החכירה עצמו ברור כי לו יתאפשר להפריד בין היחידה הרישומית של המחסן לזו של יתר דירה 15, ייעשה הדבר ואז תירשם זכות בעלותם המלאה של החוכרים במחסן (ראה למשל בסעיף 33 לחוזה). יתרה מכך. בהסכם זה לא נקבע כי לעניין פרק ו' לחוק לא יראו את החוכרים, בן חמו ופרבר, כבעלים, ככל שהדברים נוגעים למחסן.

83. במכלול נסיבות אלו, ובשים לב לכוונת הצדדים המשתמעת מהחוזה, הרי שהמחכיר, קספר, התכוון להעניק לחוכרים, בן חמו ופרבר, זכות הקרובה עד שכמה שניתן לזכות הבעלות במחסן. בשים לב לסיפא של הגדרת "בעל דירה" בסעיף 52, הרי שאף לא נקבע בחוזה החכירה שלעניין פרק ו' לחוק לא יראו את החוכרים לדורות כבעלי דירה.

84. לגופו של עניין, לא עלה בידי התובעים להוכיח כל קשר ישיר של קספר אל עבודות הבנייה וההרחבה שבוצעו במחסן (לרבות ידיעה), כמו גם לשימוש הייחודי ברכוש המשותף. אף בחקירתם הודו התובעים כי קספר הוסף לתביעה נוכח אחריותו כבעליה הרשומים של דירה 15, ולא משום שנטען כי הרחבת המחסן או תפיסת החזקה ברכוש המשותף בוצעו בידיעתו. כך למשל, השיב יגאל בר בחקירתו לעו"ד קספר:

" ש. האם אתה טוען שאני ביצעתי את אחת מפעולות הבנייה שאתה מתאר בכתב התביעה?

ת. אני טוען שאתה כבעל הנכס אחראי, אני לא טוען שבאופן אישי ביצעתי". (ראה פרוטוקול מיום 20.9.15, עמ' 5 שורות 33-34).

85. בנסיבות אלו, ונוכח האמור בהסכמי החכירה, הרי שזיקתו הנטענת של קספר מהמחסן ניתקה עם החכרתו לידי הנתבעים 2 ו-3. הדברים נכונים בפרט בכל הנוגע לעבודות בנייה שבוצעו במחסן או שימוש שנעשה ברכוש המשותף הסמוך פיסית למחסן. לא הוכח ואף לא נטען כי בכל הנוגע למחסן ביצע קספר מעשים כאלו או אחרים בעצמו או שכלל ידע על הבנייה בעת שבוצעה. היות והטענה לאחריותו נובעת משום רישומו כבעלים, הרי שביחס לזכויות במחסן יש לראות את הנתבעים 2-3 כמי שבאים בנעליו, בהיותם בעלי הזכויות הדומות כמעט באופן מוחלט לזכויות הבעלות.

86. **לפיכך מצאתי לדחות את התביעה כנגד הנתבע 1 בשלמותה.**



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: + 1/310/13, 1/213/2013

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

טענות נתבעים 2-3 להשתק או מניעות

87. הנתבעים 2-3 טוענים כי יש לדחות את התביעה כנגדם מטעמי השתק ומניעות. לטענתם, החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים בתיק מס' 2927/12 מיום 12.2.13, (להלן: "**ההליך המנהלי**"), מקימה השתק מן התובעים בהליך דנן מלתבוע את הנתבעים בגין אותם מעשים בגינם התנהל ההליך המנהלי, כאשר הצדדים שם הגיעו ביניהם להסכמה והחלטה ניתנה בהתאם לה.

88. דינה של טענה זו להידחות.

89. הכלל של מעשה בית דין קובע כי "**מקום שתביעה נידונה לגופה והוכרעה על-ידי בית-משפט מוסמך, שוב אסור להיזקק לתביעה נוספת בין אותם הצדדים או חליפיהם, אם זו מבוססת על עילה זהה**" (ר': א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, 86, ראה גם ע"א 823/08 חזן נ' רשות המסים – פקיד שומה נתניה, פסקה 7 (פורסם בבנו), 4.1.2009).

90. עוד נפסק כי מקום שהתובע יכול היה לרכז את כל העובדות ואת כל הטענות הנוגעות למעשה במסגרת ההתדיינות הראשונה, תיחשבה שתי התובענות כנסמכות על עילות זהות (ראו: ע"א 1650/00 זיסר נ' משרד הבינוי והשיכון, פ"ד נז(5) 166, 181 (2003), 181; ע"א 2035/03 לב יסמין בע"מ נ' ת.ג.י. בע"מ, פ"ד נח(6) 453, 447 (2004)).

91. הנה כי כן, תנאי להחלת מעשה בית דין הוא כי מדובר בשתי התדיינויות להם היו שותפים אותם צדדים, או חליפיהם. במקרה הנדון, ההליך המקביל הוא הליך מינהלי אשר הוגש בהתאם לסעיף 212 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה- 1965 ("הריסה ללא הרשעה"). לפיכך, הוא איננו מופנה כנגד בעל דין מסוים כלל. נכון הדבר כי בדיון שהתקיים במסגרת ההליך המקביל נכח בן חמו ובמסגרת זו הוא הגיע להסדר עם התביעה. דא עקא, כי אין ללמוד מכך שיש לראות את בן חמו כצד פורמלי לאותו הליך.

92. אף בהנחה שניתן לראות בבן חמו צד להליך המינהלי, הרי שגם אז אין להחיל את כללי ההשתק והמניעות. בעוד שבמצב דברים זה הצדדים להליך המינהלי הם מדינת ישראל והנתבע 2, בהליך דנן מדובר בתובעים שהם בעלי דירות בבית משותף, וככאלו הם כלל אינם צד בהליך המינהלי. יתרה מכך, הנתבעים 1 ו-3 כלל לא היו בעלי דין בהליך המינהלי. למעשה די בכך כדי לדחות את הטענה.

93. למעלה מן הצורך יצוין עוד כי ההליכים לפי דיני התכנון והבניה, הם שונים ונפרדים לחלוטין מאלו הנדונים לפי חוק המקרקעין, במסגרת האחרונים מתבררת מערכת היחסים שבין בעלי הדירות לבין עצמם. במצב דברים זה פסק הדין בהליך המינהלי, יהא אשר יהא, משמעו הכרעה ברובד הנוגע לדיני התכנון והבניה בלבד. אין בו כדי לקבוע דבר ברובד הקנייני הנוגע למערכת היחסים שבין בעלי הדירות. כך למשל, לא אחת קורה כי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: + 1/310/13, 1/213/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

בעוד שבהליך התכנוני ניתן היתר בניה, הרי שברובד האזרחי נמצא כי לא ניתן לבצע את הבניה נוכח היעדר הסכמת בעלי הדירות כנדרש מן הבחינה הקניינית. כך גם להפך- בעוד שבהליך התכנוני יתכן ויקבע כי אין עבירה על דיני התכנון והבניה ולפיכך אין מקום ליתן צו הריסה, יימצא ברובד הקנייני כי הבניה אינה תואמת את דרישות חוק המקרקעין (כך למשל משום שלא נעשתה בהסכמת בעלי הדירות כנדרש בחוק זה), ולפיכך יהא מקום להורות על הריסה.

94. נוכח התכליות השונות, הוראות הדינים הנפרדות, וכאמור, הצדדים השונים להליכים הנפרדים, הרי שאין בקביעות בהליך האחד כדי ליצור מניעות או השתק מקיום הדיון בהליך האחר. לפיכך, גם במקרה דנן, העובדה כי זה מכבר נקבעו, במסגרת ההליך המינהלי, קביעות ביחס לבניה שביצע הנתבע 2 במחסן וברכוש המשותף, אין בה כדי למנוע את הדיון בהליך זה, להקים השתק או מניעות מצד התובעים לתבוע את הנתבעים בהליך זה, או לכבול את שיקול דעת הערכאה השיפוטית דנן.

95. הנתבעים 2-3 טענו בהקשר זה גם לחלותו של הכלל בדבר "השתק שיפוטי", אולם טענה זו איננה ממך העניין. כלל ההשתק השיפוטי משמעו כי בעל דין שטען טענה בהליך אחד וטענתו התקבלה, מושתק מלהתכחש לטענתו גם בהליך נגד יריב אחר ולטעון טענה הפוכה (ראה למשל: עא 513/89 *S/interlego a* - *lines bros. S.a*, פ"ד מח (4) 133). בפסיקה נקבע כי אחד התנאים לקיומו של השתק שיפוטי הוא הצלחה בהליך הקודם, כלומר, כי בעל־הדין שכלפיו נטען ההשתק השיפוטי זכה בהליך הראשון על סמך טענה שאת היפוכה הוא טוען בהליך השני (ראה: לדוגמה רע"א 6753/96 *מ.מ.ח.ת.בע"מ נ' פרידמן*, פ"ד נ(5) 418, בעמ' 422). אין אלו נסיבות המקרה דנן. כאמור, כלל לא מדובר באותם צדדים וממילא לא נטען כי נטענו טענות סותרות בהליכים שונים.

טענות התובעים בדבר שימוש חורג וסטייה מהיתר

96. מטעמים דומים, הנעוצים בהפרדה שבין דיני התכנון והבניה לדיני הקניין, יש לדחות את טענות התובעים לשימוש חורג ולסטייה מהיתרי בניה. התובעים טענו, כאמור, כי הנתבעים או מי מטעמם עושים שימוש חורג במחסן לצרכי מגורים, ללא היתר לכך ושלא כדון, ולפיכך יש להורות להם להשיב את המחסן לייעודו המקורי. טענות בדבר שימוש חורג, או שימוש בדירה לייעוד שאינו תואם את היתרי הבניה החלים, הן טענות מתחומי דיני התכנון והבניה. לא אחת נפסק, כי אין להשוות בין ההסכמות והשיקולים הנוגעים לדיני התכנון והבניה לשיקולים והדרישות הנובעים מחוק המקרקעין (להבדל בין שיקולי הקניין לשיקולי ועדות התכנון ראה למשל בג"צ 1578/90, *הלן אייזן נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב*, ניתן ביום 24.10.90, פורסם ב"נבו").

97. בשים לב לכך שהתובעים טענו לשינוי ייעוד ושוש חורג ולא טענו בהקשר למעשים אלו כל טענה קניינית אחרת הנוגעת להפרת הוראות חוק המקרקעין, הרי שאין בסמכותי לדון בטענות מסוג זה. התובעים רשאים להעלות טענות אלו בפני הערכאות המוסמכות, ככל שהם חפצים בכך.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: + 1/310/13, 1/213/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

טענת הנתבעים בדבר שימוש באחוזה הבניה כפי שהותר להם בחוזה החכירה

98. לקראת סיום יש לדחות גם את טענת הנתבעים 2-3 לפיה לצורך שימוש באחוזה הבניה הקיימים, די בהסכמת בעל יחידה 15, כפי שניתנה להם בשטר החכירה, ולתובעים אין כל פתחון פה בעניין.

99. זכויות בנייה אינן מהוות חלק מהרכוש המשותף (ראה ע"א 136/63 לוינהיים נ' שורצמן, פ"ד יז 1726, 1723 (1963), ע"א 432/83 מזרחי נ' חביב, פ"ד מ(4) 673, 680 (1986), ע"א 19/81, ביבי נ' הוברט, פ"ד לו (2) 497, 501, להלן: "עניין ביבי") עם זאת נקבע כי מדובר בנכס כלכלי בעל ערך המצוי בבעלות משותפת של כלל בעלי הדירות (ראה עניין ביבי, ע"א 11965/05 עזבון המנוח מרדכי קליין נ' דוד שרון, תק- על 2009 (3), 3111- להלן: "עניין קליין").

100. עוד נקבע, כי על זכויות בנייה ניתן להתנות באמצעות הסכמות חוזיות, להן גם ניתן ליתן ביטוי בתקנון הבית המשותף, אולם זאת יש לעשות באמצעות הסכמה מפורשת של כל בעלי הדירות (רע"א 2912/11, יקיר נ' לוי, פורסם ב"נבו", ניתן ביום 26.5.11, ע"א 3451/07 קאופמן נ' כהן, פורסם בנבו, ניתן ביום 18.2.10, עניין ביבי, ע"א 7156/96, שואעי נ' בכרך, פ"ד נג (1) 469).

101. ככלל, כל עוד אין הוראה אחרת בתקנון המוסכם או בכל מסגרת ראויה אחרת, זכויות הבנייה הן בבעלות משותפת של כל בעלי הדירות, וכאלה הן מחולקות, כברירת מחדל, בין כל בעלי הדירות בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, כך שאין לבעל דירה חלק מסוים פרטני בהן (ראה: עניין קליין). לפיכך, אין בעל דירה יכול לנצל- אף לא את חלקו היחסי בזכויות הבניה- ללא קבלת הסכמת בעלי הדירות לכך כדין.

102. בעניינינו כולל התקנון המוסכם הוראות שונות אשר מבלי לקבוע בכך מסמרות ניתן לפרשן ככאלה המעניקות את זכויות הבנייה בגג לבעלי היחידות אליהן צמוד הגג, ובכלל זה דירה 15 (ראה התקנון המוסכם- נספח ב1 לתצהיר יגאל בר). עם זאת, עיון בחוזה החכירה ובנספח ה"תנאים מיוחדים" מלמד כי המוכר (קספר) ממילא לא חילק או העביר לחוכרי המחסן פרבר ובן חמו את זכויות הבניה של יחידה 15, "למעט זכויות הבנייה הדרושות כדי להשתמש במחסן הקיים, ללא תוספות (קרי 16 מ"ר) לשם מגורים" (ראה בסעיף 7 לחוזה החכירה ובסעיף 15 ל"תנאים המיוחדים"). יתרה מכך, בסעיף 12 לתנאים המיוחדים הובהר כי קספר נתן הסכמתו לעבודות בנייה שונות ורחבות "למעט תוספות בניה לפי חוק התכנון והבניה". לפיכך, מהאמור בחוזה החכירה ונספחיו עולה כי קספר עצמו לא העניק לבן חמו ופרבר ולו חלק מזכויות הבניה הקיימות על הגג לשם הרחבה או ביצוע כל תוספת אחרת לפי חוקי התכנון והבניה (ככל שבכלל ניתן להעביר את אחוזי הבניה מהגג למחסן, והדבר מוטל בספק רב).

103. מכל מקום, אף אם היה ניתן להעביר זכויות בניה מהגג למחסן (וכאמור הדבר לא הוכח כלל), הרי שגם אז- בשים לב לכך שגם התובע 1 אוזח לפי התקנון בזכויות בניה על הגג (מכוח היותו בעלי תת חלקה 16 לה גם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: + 1/310/13, 1/213/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

צמוד חלק מהגג), היה צורך לכל הפחות לקבל לשם כך את הסכמתו, וזו לא ניתנה. יוער, כי מהתקנון המוסכם לא ניתן ללמוד על חלוקה ברורה של זכויות הבנייה בגג בין דירה 15 לדירה 16 ולפיכך לכאורה אוחד כל אחד מהם בחלק בלתי מסוים מזכויות הבנייה בגג. במצב דברים זה הרי שבהיעדר הסכמת התובע 1 אין תוקף להעברת זכויות הבנייה מהגג למחסן, ככל שנעשתה, אף לא לצורך שימוש למגורים.

104. מורם מן האמור לעיל כי לא הוכח שניתנה הסכמת הנתבע 1 לשם ניצול זכויות בניה לצורך הרחבת המחסן, וממילא אף אם הייתה ניתנת, לא הוכח כי אכן היה לכך תוקף, וכי הנתבע 1 אחז ביכולת המשפטית לתיתה.

105. אשר על כן יש לדחות את טענת נתבעים 2-3 לפיהן עשו שימוש באחוזי הבניה כפי שהותר להם בהסכם החכירה.

התביעה שכנגד

ה. עיקרי טענות הנתבעים (התובעים שכנגד) בכתב התביעה שכנגד

106. לטענת הנתבעים, התובעים 1 ו-7, בר ורפאל בר, הסירו את הקיר החוצץ בין דירות 1 ו-6 ו-7 וחילקו אותן מחדש, באופן שנוצרו 2 יחידות חדשות. איחוד הדירות וחלוקתן מחדש, כך נטען, נעשו בלא היתר בניה כדין, ומבלי שניתנה לשם כך הסכמת יתר בעלי הדירות. עוד נטען כי ביחידות שנוצרו נעשה שימוש חורג ללא היתר, בין היתר, בהפיכת דירת מגורים לחנות.

107. עוד נטען כי הנתבעים 1 ו-7 התקינו גג מעל מבואה/ חצר המפרידה בין המחסן של דירה 16 לבין דירה 7 ודירה 1, והרחיבו את שטחן ללא היתר בנייה. עוד נטען כי הנתבעים 1 ו-7 פרצו פתח בקיר החיצוני המערבי של דירה 7 ויצרו מעבר וחיבור מדירה 7 למחסן של דירה 16 ובמקביל אטמו את דלת הכניסה הקיימת של דירה 7. נטען כי אטימת הפתח ופריצת פתח חדש נעשו ללא היתר בניה מבלי שניתנה לשם כך הסכמת כל בעלי הדירות.

108. בנוסף נטען כי הנתבעים 1 ו-7 או מי מהם הניחו על הרכוש המשותף ועל הקירות החיצוניים של הבית מקררים או מדחסים רבי עוצמה לשימוש החנויות שהכשירו בדירות 1 ו-6 ו-7. נטען כי הפעלתם גורמת לרעש בעוצמה רבה, החורג מן המותר בחוק. עוד נטען כי הסבת הדירה לחנות גורמת למטרד, נוכח הצטברות נטענת של אשפה ולכלוך. עוד נטען כי יש בהצבת מתקנים ומדחסים אלו משום שימוש בלתי סביר ברכוש המשותף, ויש שבו משום פגיעה במראה הבניין ובחזותו.

109. נטען כי במעשיהם אלו הנתבעים 1 ו-7, יגאל בר ורפאל בר, פגעו ברכוש המשותף, גזלו משטחו, פגעו במראה הבניין וחזותו, יצרו יחידות נוספות בניגוד למסמכי הבית המשותף תוך ניצול שלא כדין של אחוזי בנייה, ותוף שהם מבצעים ביחידות אלה שימוש חורג ללא היתר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: + 1/310/13, 1/213/2013

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

110. הנתבעים טוענים עוד כי התובע 2 והנתבע שכנגד 8, יזהר עירוני ונתן עירוני, ביצעו בדירה 2, המוגדרת כחנות, עבודות בניה שלא כדין ובין היתר בנו בה גלריה והתקינו בה שירותים, במטרה להכשירה למגורים. נטען, כי בניית הגלריה יצרה קומה נוספת בבניין, והגדילה את שטח דירה 2 ללא קבלת היתר בנייה כדין ומבלי לקבל לשם כך את הסכמת יתר בעלי הדירות.

111. נטען עוד כי יזהר עירוני, עת היה הבעלים של תת חלקה 5, המוגדרת כמשרד, בנה גלריה בדירה שלא כדין וללא היתר בנייה, הגדיל את שטח יחידה זו והפך אותו לדירת מגורים, וזאת "בניגוד למסמכי הבית המשותף וללא היתר בנייה".

112. עוד טוענים הנתבעים כי רפאל בר הפך את תת חלקה 6 ממשרד לחנות למכירת פיצה. כמו כן התקין בחצר ובקירות הבית מכונות ומתקנים הגורמים לרעש בלתי סביר החורג מן הסביר והמותר על חוק.

113. ביחס לכך ולכך נכסים, הנתבעים טוענים כי אלו סגרו מרפסת אחורית בתת חלקה 13, צרפו את שטח המרפסת לדירתם, וזאת באופן ששטח דירה 13 הוגדל, תוך פגיעה בחזות הבניין, גזילת אחוזי בנייה ופגיעה ברכוש המשותף.

114. אשר על כן עתרו הנתבעים בתביעתם שכנגד לסעדים הבאים:

" לנתבעים שכנגד 1 ו-7 או מי מהם:

א. להחזיר לקדמותו את מצבן של דירות 1 ו-7.

ב. להפסיק את השימוש בדירה 7 כחנות ולהחזיר את השימוש בה למגורים.

ג. להסיר ו/או להרוס את הגג שהתקינו בין דירות 1 ו-7 לבין דירה 16.

ד. לאטום את הפתח החדש שקבעו בדירה 7 ולהסיר את אטימת פתח הכניסה לדירה 7.

ה. להסיר את המזגנים ו/או המדחסים ו/או המקררים שהניחו בחצר ובקירות הבית, ולהפסיק את השימוש בהם.

ו. להחזיר את השימוש בדירה 6 למשרד ולחדול מלהשתמש בה כחנות.

ז. להסיר את המדחסים והמתקנים שהתקינו לצרכיה של דירה 6 ולחדול מן השימוש בהם.

לנתבעים שכנגד 2 ו-8 או מי מהם:

ח. להרוס ולבטל את הגלריה שבנו בדירה 2.

ט. להפסיק את השימוש בדירה 2 למגורים ולהחזיר את השימוש בה כחנות.

לנתבעים שכנגד 3 ו-4 או מי מהם:

י. להחזיר את מצב המרפסת של דירה 13 לקדמותו ולבטל את השימוש בה כחלק מהדירה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: + 1/310/13, 1/213/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

יא. לחייב את כל הנתבעים שכנגד לשלם לתובעים שכנגד הוצאות משפט שכ"ט עו"ד ומע"מ".

ו. עיקרי טענות התובעים (הנתבעים שכנגד) ביחס לתביעה שכנגד

115. בכל הנוגע לתביעה שכנגד טוענים התובעים כי יש לדחות את התביעה בהיעדר עילת תביעה וכן מטעמי השתק ומניעות.

116. התובעים טוענים כי מדובר בתביעה קנטרנית שהוגשה רק בכדי להוות כביכול משקל נגד כנגד תביעתם שלהם, ולכן יש לדחותה ולו אך בשל שימוש לרעה בהליכי משפט, חוסר תום לב וחוסר ניקיון כפיים. עוד טוענים התובעים כי הטענות המפורטות בכתב התביעה שכנגד התיישנו זה מכבר.

117. לגופו של עניין טוענים התובעים כי יגאל ורפאל בר ביצעו לפני עשרות שנים שינויים של החלוקה הפנימית בדירות 1,6 ו-7 המצויות בבעלותם. נטען כי לא בוצעה כל בנייה על שטחים משותפים, וממילא כי השינויים שנעשו נעשו בהסכמת כל בעלי הזכויות באותה תקופה.

118. נטען עוד כי תת חלקה 16 שייכת ליגאל בר, והעבודות שבוצעו בוצעו בתחום רכוש הפרטי בלבד. נטען כי לא בוצעה לתת חלקה 16 כל הרחבה וממילא לא בוצעה אטימה או פתיחה בשונה מהרשום בתשריט הבית המשותף. נטען כי דלת הכניסה המחברת בין המחסן המסומן 16 (המהווה קניינו הבלעדי של יגאל בר) לתת חלקה 7 עומדת על תילה מימים ימימה.

119. באשר למנוע המזגן נטען כי זה הותקן בהסכמת הדיירים לפני שנים רבות, בתוך שטחו הפרטי של יגאל בר (מבואה נסתרת המתוחמת משלוש פאותיה), ואין בכך כל פסול. נטען עוד בהקשר זה כי התקנת מנוע מזגן מהווה ממילא שימוש סביר ומותר ברכוש המשותף.

ז. דיון והכרעה

פיצול מחדש של דירות 1 ו-6 ו-7 –

120. בהקשר זה נטען, כזכור, לחלוקת דירות 1 ו-6 ו-7 מחדש באופן בו נוצרו 2 דירות חדשות שאינן בתוואי המקורי שלהן.

121. מדובר באופן ברור בחלוקה פנימית של שתי דירות אלו, ללא כל תוספת או הרחבה נטענת לתחומי הרכוש המשותף. הנתבעים לא הוכיחו כי יש בחלוקה זו בכדי לפגוע באופן כלשהו בזכויותיהם או בבית המשותף-חזותו, מראהו וכיוצא בזה. בנסיבות אלו, הרי שלחלוקה פנימית זו לא נדרשת הסכמת יתר בעלי הדירות, או חלקם, כלל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: + 1/310/13, 1/213/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

122. בכל הנוגע לטענות בדבר שימוש החורג מזה המותר לפי התוכניות החלות, הרי שכאמור טענות בדבר שימוש חורג, או שימוש בדירה ליעוד שאינו תואם את היתרי הבניה החלים, הן טענות מתחומי דיני התכנון והבניה. התובעים לא הוכיחו בהקשר למעשים אלו כל הפרה של הוראות חוק המקרקעין, ולפיכך, כפי שכבר ציינתי לעיל, אין בסמכותי לדון בטענות מסוג זה.

123. למעלה מן הצורך אעיר כי לגופו של עניין התובעים הראו כי ביחס לדירות 1 ו-6 ניתן היתר בנייה ל"תוספת דלת בחזית ושינויים פנימיים" (ראה מוצג נ/2). לשינויים פנימיים אלו, עליהם למעשה מלינים התובעים, נתנו את הסכמתם רוב מוחלט מבין בעלי הדירות, כעולה מחתימות בעלי הדירות על מסמך "הסכמה לביצוע עבודות הטעונות היתר בנייה מיום 16.6.09 (ראה בעמ' השני של מוצג נ/2).

התקנת גג בין דירות 1 ו-7 למחסן של יחידה 16, פריצת פתח ואטימת פתח קיים-

124. יחידה 16, כאמור, גם היא בבעלותו של יגאל בר. נטען, כאמור, כי בין דירות 1 ו-7 לבין המחסן ששייך לדירה 16 הותקן גג ונפרץ פתח חדש חלף זה שהיה קיים במקור. מעיון בתשריט הבית המשותף (מוצג ת/2) עולה כי מחסן דירה 16 ממוקם בתחום המסומן באות א' והצבוע באדום. על פי האמור בתקנון הבית המשותף, - סעיף 1א' לתקנון- כל השטח המסומן א', והממוקם כאמור, בסמוך ליחידות 1 ו-7, מוצמד ליחידה 16.

125. במצב דברים זה, הרי שהגג שהותקן בין יחידות 1 ו-7 למחסן 16, נעשה בתחום ההצמדה השייכת לתת חלקה 16. לא הוכח כלל כי מדובר בהרחבה כנטען, שכן אין בהצבת גג המקשר בין הדירה למחסן כדי ללמד על הרחבת דירה. לפיכך לא מצאתי כי יש לכך כל השלכה לא כל שכן פגיעה ברכוש המשותף. בתקנון המוסכם מצוין כי בחצר המסומנת א' (שם גם נטען כי בוצע הקירוי האמור) תהיה זכות מעבר למחסן השייך ליחידה 8 וכלל לא נטען כי יש בקירוי יש משום פגיעה בזכות מעבר זו.

126. באשר לטענה בדבר פתיחת פתח קיים ואטימת פתח מקורי בין יחידות 1 ו-7 למחסן שבבעלות יחידה 16, הרי שהדבר כלל לא הוכח. בתצהיר עדותו הראשית הכחיש יגאל בר לחלוטין את שינוי הפתחים כנטען (ראה בסעיף 39 לתצהירו) וטען כי אלו היה כך במקור. בחקירתו הנגדית, לא נשאל יגאל בר על סוגיה ספציפית זו וממילא דבריו לא הופרכו.

הנחת מדחסים על הרכוש המשותף לשימוש החנויות בדירות 1 ו-6 ו-7-

127. לא הוכח כי המדחסים המשמשים את דירות 1 ו-7 מונחים ברכוש המשותף. טענת יגאל בר כי אלו מונחים בתחומי רכוש הפרטי – באותו שטח קרקע המסומן א' ומוצמד ליחידה 16 אשר בבעלותו- לא הופרכו.

128. באשר לטענה בדבר מטרד, הרי שמעבר להיעדר סמכותי לדון בסוגיה זו (שכן מדובר במטרד המהווה עילה נזיקית שכלל אינה בסמכות המפקח על רישום מקרקעין- ראה ד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733, ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: + 1/310/13, 1/213/2013

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

פ"ד כ"ד (1) 231, לא הוכיחו הנתבעים כלל וכלל כי אכן המדחסים המוצבים בחצר המשותפת גורמים לרעש בלתי סביר החורג מהמותר על פי חוק, כפי שנטען. כך, לא הציגו הנתבעים כל חוות דעת מומחה או ראייה אחרת שיש בה כדי לבסס את הטענה.

129. נותר לדון בטענות בדבר שימוש בלתי סביר ברכוש המשותף בהתקנת מדחסים אלו, ושינוי חזות הבניין ללא הסכמת בעלי הדירות כדין. בסיכומיהם טענו הנתבעים 2-3 כי נושא זה הוכח הן נוכח האמור בסעיף 13 לתצהירו של רפאל בר והן נוכח דבריו בחקירתו הנגדית (ראה בסעיף 34 לסיכומי הנתבעים 2-3).

130. בסעיף 13 לתצהיר עדותו הראשית של רפאל בר הוא מציין כי "**המנוע למזגן הותקן לפני שנים רבות בתוך השטח אשר בבעלות הדוד שלי יגאל בר (מבואה נסתרת המתוחמת משלוש פאותיה) המסומן א' וצבוע באדום בתשריט...**". בחקירתו הנגדית ציין רפאל בר כי הוא יודע שהמתקן נמצא בחצר ואיננו יודע אם זה רכוש משותף (פרוטוקול מיום 29.4.15, עמ' 9 שורה 37) אמנם בהמשך במענה לשאלה אם המתקן מוצב היום ברכוש המשותף השיב "**כנראה שכן**", אולם במכלול נסיבות העניין אין ללמוד מדבריו אלו של בר כי הוכח שהמדחסים אכן נמצא ברכוש משותף.

131. סיכומו של דבר הוא כי לא הוכח שהמדחסים אכן מוצבים ברכוש המשותף. השטח המסומן א' והצבוע באדום בתשריט איננו רכוש משותף כי אם רכוש בבעלות הפרטית של יגאל בר ועל כן להצבת המדחסים שם ממילא לא נדרשת הסכמת בעלי הדירות.

132. באשר למדחסים אשר הותקנו על הקירות החיצוניים של הבית המשותף, הרי שעל אף שקירות חיצוניים אכן מהווים רכוש משותף (ראה בהגדרת רכוש משותף בסעיף 52 לחוק), נפסק זה מכבר כי התקנת מנועי מזגן הם ככלל בבחינת שימוש סביר ברכוש המשותף (ראה למשל בע"א (ת"א) 991/97 **נציגות הבית המשותף נ' לילי אבן** (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 13.1.98, ע"א (י-ם) 2560/01, **נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 19 נ' בית חינוך עיוורים לבני ישראל** (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 4.4.02) לא הוכח לי כי דינם של מנועי המזגן שהותקנו על קירותיו החיצוניים של הבית המשותף על ידי התובעים או ממי מהם שונה, שכן לא הוצגו כל ראיות המלמדות על גודל חריג או על כך שהם מסבים רעש בהיקף החורג מן המותר בדיון.

133. לפיכך מצאתי לדחות גם טענות אלו.

134. מהאמור לעיל עולה כי דינם של הסעדים המבוקשים כנגד התובעים 1 ו-7, יגאל בר ורפאל בר- **להידחות**.

135. **בניית "גלריה" בדירות 2 ו-5** - בניית הגלריות, כך גם על פי טענת הנתבעים, בוצעה בתוך תחומי דירות 2 ו-5 ולא היה בה כדי להוסיף לשטחי דירות אלו מתוך הרכוש המשותף. הנתבעים אמנם טענו בחצי פה כי יש בכך כדי לגזול זכויות בנייה, אולם טענה זו נטענה בעלמא ולא בוססה בראיות כלשהן. האדריכלית רונית ראובני, מטעם התובעים (הנתבעים שכנגד), טענה בחקירתה כי כאשר מדובר בבניית גלריה שגובהה מעל 1.8 מדובר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: + 1/310/13, 1/213/2013

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

כבר בניצול שטח עיקרי (ראה פרוטוקול הדיון מיום 29.4.15, עמ' 4 שורות 26-30). בחקירתו, העיד יזהר עירוני בהתייחסו לתת חלקה 5 כי מדובר בגלריה "נמוכה מאוד" אשר איננה מעל 1.8 (ראה פרוטוקול מיום 20.9.15, עמ' 2 שורות 6-9). בהתייחסו לתת חלקה 2 העיד יזהר עירוני כי קיימת גלריה מקורית, "אשר נבנתה עם הבניין ... גלריה של חלק מהמבנה שמתפרסת על פרוזדור הכניסה לבניין ששימשה לאחסון מיום שהבניין נבנה" (ראה פרוטוקול הדיון מיום 20.9.15, עמ' 2 שורה 42, עמ' 3 שורות 2-3). הנתבעים לא הפריכו עדות זו של יזהר עירוני, ולא הציגו כל ראיה המלמדת כי הגלריות, או אחת מהן, נבנו בגובה של מעל 1.8 או כי זו השייכת לתת חלקה 2 לא הייתה קיימת כך במקור. משכך, לא הוכח כי יש בעצם בניית הגלריות בהיקף בו נבנו יש משום ניצול אחוזי בנייה קיימים.

136. במצב דברים זה אין אלא לראות בהוספת הגלריות כשינוי פנימי בדירות 2 ו-5 שאין לו כל השלכה על הרכוש המשותף או יתר הדירות בבית המשותף. בכל הנוגע לשינוי ייעוד ממשרד למגורים, הרי שכאמור, משלא הועלתה כל טענה לפגיעה מעבר לסוגית שינוי היעוד עצמו, והיעדרו של היתר מתאים לכך מרשויות התכנון, הרי שמדובר בסוגיה תכנונית בלבד שאיננה בתחומי סמכותי.

137. אשר על כן, גם בהקשר זה יש לדחות את הסעדים המבוקשים.

138. שינוי דירה 6 ממשרד לחנות-

139. כאמור לעיל, מדובר בטענה נוספת של הנתבעים בה הם מלינים על שינוי ייעוד, שימוש חורג- טענות להפרת חוקי התכנון והבניה וכאמור ככאלו הן אינן מצויות בגדרי סמכותי העניינית.

סגירת מרפסת בדירה 13-

140. כלפי כץ את כץ נטען כי בדירה 13, אשר בבעלותם, קיימת מרפסת שנסגרה שלא כדין וללא הסכמת בעלי הדירות כדין.

141. מעדותו של כץ, בעליה של כץ נכסים, עלה כי רכש את דירה 13 בשנת 2008 כאשר המרפסת הייתה במצבה הנוכחי (ראה פרוטוקול מיום 29.4.15, בעמ' 15 שורות 33-36). לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי כץ או מי מטעמו הוא שביצע את סגירת מרפסת זו. הטענה בדבר "גזילת אחוזי בנייה" ככל לא הוכחה, שכן התובעים לא הציגו כל ראיה המלמדת כך.

142. באשר לטענה בדבר פגיעה בחזות הבניין, הרי שנוכח שינוי חזית הבניין המתלווה לסגירת המרפסת נדרשת הסכמת רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית (ראה סעיף 2א לתקנון המצוי). בשים לב לכך שהמרפסת נסגרה כבר לפני למעלה מ-8 שנים, ולכך שלא הובאו כלל ראיות המלמדות כי הדבר נעשה שלא בהסכמת בעלי הדירות אותה עת, הרי שאני מורה כי על כץ נכסים להסיר את סגירת המרפסת אלא אם כן תקבל את הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות להורתה של המרפסת במצבה הנוכחי על כנה וזאת בתוך 60 יום.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: + 1/310/13, 1/213/2013

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

143. יצוין כי אף כץ בעדותו הביע נכונות להסיר את סגירת המרפסת ככל שיתברר כי אכן נבנתה שלא כדין (ראה פרוטוקול הדיון מיום 29.4.16 ע' 15 שורות 39-40, עמ' 16 שורות 12-13).

ח. סוף דבר

144. התביעה(תיק 213/13) מתקבלת חלקית:

145. על הנתבעים 2-3 להנמיך את גג המחסן ב-50 מטרים, להחזירו למצבו המקורי.
146. על הנתבעים 2-3 להסיר את הריצוף כמתואר לעיל, להסיר מתחומי החצר המשותפת את כר הדשא הסינתטי, הספסלים, ובולי העץ. כמו כן על הנתבעים 2-3 להסיר את מחסן הפלסטיק שהציבו בסמוך לכניסה האחורית למחסן. נאסר על הנתבעים או מי מטעמם לעשות שימוש ייחודי כלשהו בחצר או בחלקו.
147. על הנתבעים 2-3 להסיר מתחומי הרכוש המשותף את כל הכבלים והצינורות המחוברים את המחסן לתשתיות דירה 15.
148. את כל הפעולות המנויות לעיל על הנתבעים 2-3 לבצע בתוך 30 יום מיום מתן פסק הדין.
149. יתר הסעדים המבוקשים בתביעה זו, לרבות התביעה כנגד נתבע 1- נדחים.
150. באשר לכתב התביעה שכנגד (310/13) אני מורה לנתבעים 3 ו-4 להסיר מתת חלקה 13 את סגירת המרפסת ולהשיבה למצבה המקורי טרם הסגירה, אלא אם כן תתקבל הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות להותרה של המרפסת במצבה הנוכחי על כנה וזאת בתוך 60 יום מהיום.
151. יתר הסעדים המבוקשים בכתב התביעה שכנגד- נדחים.
152. הנתבעים 2-3 ישלמו לתובעים הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך ₪ 8,500.
153. התובעים ישלמו לנתבע 1 הוצאות משפט בסך ₪ 2,000.
154. הסכומים המפורטים לעיל ישולמו בתוך 30 יום ולאחר כך יישאו הפרשי ריבית והצמדה כדין.

ניתן היום, כ"ט חשוון תשע"ז, 30 נובמבר 2016, בהיעדר הצדדים.

המזכירות תשלח לב"כ הצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

יעל ענתבי-שרון
מפקחת על רישום מקרקעין